

1507972-10.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507972-10.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507972-10.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089011/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 17099380 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 1119/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2089011 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR DANIEL MACARIO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

VICTOR DANIEL MACARIO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Conforme consta no auto de exibição e apreensão de fls. 18 e no laudo de constatação de fls. 07/10, o acusado teria trazido consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, as seguintes substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica: 100 micro tubos plásticos tipo eppendorf contendo, aproximadamente, 9,3g de cocaína na forma de "crack",

21 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 6,3g de cocaína na forma de "crack",
01 invólucro plástico contendo, aproximadamente, 0,3g de cocaína e
23 frascos plásticos contendo, aproximadamente, 15,4g de Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "skunk".

Apurou-se que VICTOR estava no local dos fatos trazendo consigo, no interior de uma sacola plástica, as porções de drogas acima descritas, com a finalidade de entregá-las ao consumo de terceiros, além da quantia de R\$ 405,00 em espécie, proveniente da venda de entorpecentes. A conduta típica apenas ter-se-ia encerrado quando os Policiais Militares componentes das monoviaturas M-09483 e M-09492, que realizavam patrulhamento pelo local, avistaram o denunciado parado em frente à entrada de uma viela onde fica localizado um escadão, em atitude suspeita, e deliberaram pela abordagem.

Em vistoria na sacola plástica que o denunciado carregava, os policiais localizaram as citadas porções de drogas e, em busca pessoal, localizaram a quantia em espécie e um telefone celular.

Notificado o réu (fls. 120), apresentou a defesa prévia (fls. 105). Inviável a absolvição sumária, foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento (fls. 125).

Encontram-se nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 11 e 12/13), o boletim de ocorrência (fls. 14/16), o auto de exibição e apreensão (fls. 18), o laudo de constatação provisória (fls. 112/115) e o laudo químico toxicológico, fls. 149/151. Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos dois policiais militares e o réu interrogado ao final.

Ouvidas as partes em debates orais, a acusação pleiteou a condenação e concordou com a aplicação do privilégio em seu percentual médio e com regime aberto e a defesa pleiteou a aplicação do privilégio em seu percentual máximo, regime aberto e substituição da pena em restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.18) e dos laudos de constatação provisória (fls. 112/115), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 149/151), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva, vejamos

Igor, policial militar, se recordou do acusado. Equipe em patrulhamento de duas rodas, visualizou 3 indivíduos na frente de uma viela, conhecida como ponto de tráfico. Já fez outras prisões no local. Ao perceberem a polícia todos correram, mas o acusado foi detido. Nas mãos dele aprendeu uma sacola com substâncias entorpecentes fracionadas para a venda, em invólucros. No bolso, 450,00 em cédulas de pequeno valor. Ele admitiu a prática há 4 dias e que receberia cerca de 150,00 por dia. Os fatos ocorreram no período da manhã.

O policial Felipe reconheceu o acusado, de uma coreografia de tráfico de Drogas, Rua Doutor Araújo Castro, numeral 90. Estava na equipe de motocicleta. O local já era conhecido por tráfico. Na altura do número 90, no começo de uma escadaria, viu três indivíduos que correram, mas Victor foi abordado. Ele portava uma sacola plástica com dinheiro e entorpecentes. Cerca de quatrocentos e poucos reais em notas pequenas. O entorpecente fracionado para venda, cocaína, crack e skunk. Os fatos ocorreram por volta da hora do almoço. Ele admitiu que estava no tráfico há uns 4 dias. Ele admitiu que tinha passagens por roubo.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta

delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Além de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos a confissão do acusado obtida em juízo, vejamos.

Vítor tem 19 anos de idade. Mora com a família, com os avós. Faz bico de catar papelão. Está esperando a vaga na escola. Quando ainda adolescente foi processado por roubo. Estava no local com a marmita, e estava no tráfico. O entorpecente era do interrogando, mas estava um pouquinho distante e era para a pratica de tráfico. Não se recorda se havia outras pessoas. Reconhece que estava trabalhando no tráfico há quatro dias. Ficou 16 dias preso pelos fatos. Não é usuário. Admite que estava com todo o entorpecente apreendido.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante referente a calamidade pública eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua prática. Não há prova de nexo causal. De igual forma, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo lega.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 em sua carga redutora máxima. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls. 87. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaíam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em

si. E, seguindo-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, no caso pouca quantidade de entorpecente - ao todo 31,3g - é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 1.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Carmen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno VICTOR DANIEL MACARIO DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato. Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição,

ou seja, suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 18). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06;

Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Isento de custas.

Publicada em audiência.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA